

1500371-10.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... fim, que Lucas já é pessoa experiente na prática do tráfico de drogas, pois cumpre pena pelo mesmo delito, e ainda na eventual possibilidade de que em alguns meses pudesse requerer a progressão de regime de cumprimento de pena, optou por voltar a se imiscuir com o tráfico de drogas.

A materialidade igualmente restou comprovada, porquanto a respeito da conduta delitiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N

CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070

FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1500371-10.2022.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500371-10.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor

Réu

Justiça Pública

Lucas Moreira dos Santos e João Inácio Neto dos Reis

Réu Preso

Vistos.

Lucas Moreira dos Santos e João Inácio Neto dos Reis foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e estão sendo processados por incursão no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de março de 2022, por volta de 09h30min, na Av. Arcênio Riema nº 1675, bairro Industrial Una, nesta cidade e comarca de Taubaté, traziam consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas imediações de estabelecimento prisional.

Descreve a denúncia que o réu João Inácio tinha consigo, num invólucro plástico transparente, 30 (trinta) porções de maconha, e o réu Lucas, em uma sacola plástica, outras 30 (trinta) porções da mesma droga. Ambos cumprem pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha e, quando dos fatos, estavam se preparando para retornar do gozo do benefício de saída temporária. As drogas estavam embaladas e preparadas para serem engolidas - forma por eles utilizada para ingressar no estabelecimento prisional com o entorpecente -, inclusive Lucas já havia engolido duas porções quando acabaram surpreendidos em um bar localizado nas proximidades daquele estabelecimento prisional, por policiais civis, os quais lograram encontrar e apreender a droga e prendê-los em flagrante delito (fls. 76/77).

Recebida a denúncia, em 13 de abril de 2022 (fls. 82/85), os réus Lucas e João foram citados (respectivamente a fls. 117 e 118) e apresentaram resposta escrita à acusação, em que impugnaram a pretensão acusatória (fls. 124).

Saneado o processo (fls. 128/129), realizou-se audiência de instrução por teleconferência, mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, cujo registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 157/158).

Na oportunidade procedeu-se à inquirição das testemunhas do rol acusatório, comuns às defesas, e ao interrogatório dos réus; seguiu-se a apresentação de alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia, ressaltando que a autoria é incontestada frente à prova oral produzida, restando a versão dos réus implausível frente à narrativa dos policiais. Postulou o arbitramento das penas-base nos mínimos legais; a incidência da agravante da reincidência, específica na hipótese, e da causa de aumento de pena descrita na denúncia, diante da proximidade do local dos fatos com o estabelecimento prisional, onde os réus tinham o intuito de ingressar com os entorpecentes, e que não seja aplicado o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência dos réus, cominando-se o regime fechado para início de cumprimento de pena.

A defesa do réu Lucas requereu a desclassificação da imputação do crime de tráfico de drogas para aquele tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, de posse de drogas para uso próprio, considerando o teor do interrogatório do réu em juízo. Em caso de condenação, pugnou haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Já a defesa do réu João pugnou por absolvição por insuficiência probatória, sustentando a fragilidade das provas quanto à vinculação do réu às drogas apreendidas, aliada à sua negativa de autoria em todas as oportunidades em que ouvido, presença de vários outros detentos no local dos fatos, que era público, e incoerência de prática delitiva estando na iminência de progredir para o regime aberto. Para o caso de condenação, pleiteou o arbitramento das penas-base nos mínimos legais, reconhecendo-se a reincidência. Por fim, pleiteou os benefícios da justiça gratuita, pois representado o réu pela Defensoria Pública.

É o relatório.
Decido.

Os réus estão sendo acusados do crime de tráfico de drogas, com majorante por ter sido praticado nas imediações de estabelecimento prisional.

Inquiridos quando da lavratura do flagrante, os policiais civis Guilherme Marcondes Pereira de Oliveira e Leandro César de Oliveira narraram que realizaram denominada "operação saidinha" após trabalho de inteligência do setor da delegacia especializada em conjunto com o setor de inteligência do presídio Pemanó [Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha], visando coibir que presos que estavam retornando da saída temporária ingressassem no estabelecimento prisional com drogas. Deslocaram-se até as imediações do presídio, onde permaneceram em campana. Ficaram numa rua transversal à avenida do local dos fatos, a uma distância em que puderam observar uma movimentação suspeita nos fundos do bar, típica de tráfico de drogas, razão para que tenham resolvido abordar os réus. João estava no interior do banheiro. Quando saiu para ser revistado, foi localizado no centro do chão do banheiro um invólucro plástico transparente contendo 30 (trinta) porções de maconha, embaladas e preparadas para serem engolidas. O banheiro era pequeno e de uso individual, onde só estava o réu João. Prosseguindo nas revistas pelo local, foi localizada na parte externa do banheiro, junto a Lucas, no chão, uma sacola plástica com os pertences de Lucas e, ao seu lado, um

outro invólucro transparente contendo mais 30 (trinta) porções de maconha preparadas para serem engolidas. Indagado, Lucas confirmou que a sacola na cor amarela era de sua propriedade, confessando que iria engolir drogas para levar para dentro do presídio Pemanó (fls. 02 e 03, respectivamente).

Inquiridos em juízo, os mesmos policiais civis apresentaram narrativas uníssonas à da fase policial. Em acréscimo, ambos narraram que durante a abordagem deram ordem para que João saísse do banheiro, que era um local bem pequeno, em que não caberiam duas pessoas. Lucas estava do lado de fora do banheiro. João negou a propriedade das drogas localizadas no centro do banheiro, enquanto Lucas confessou que iria engolir os entorpecentes localizados fora do banheiro, a fim de com eles adentrar no presídio, porém, também não assumiu a propriedade da sacola de entorpecentes do banheiro. Não conheciam os réus antes dos fatos.

O PC Guilherme ainda relatou que havia vários policiais civis na operação e que, juntamente com o PC Leandro, descaracterizados, desceram da viatura e procederam às abordagens. Durante a movimentação por eles observada notaram várias pessoas saindo e entrando do banheiro, que não foram abordadas. A droga localizada no interior do banheiro não estava oculta. No local havia vaso sanitário, mas não testou o seu funcionamento. O banheiro era de uso público. Apenas visualizou João saindo do banheiro, mas não ingressando.

O PC Leandro informou que Lucas foi conduzido até o pronto-socorro, pois ele comentou que já havia ingerido algumas porções de entorpecentes. O bar do local dos fatos localizava-se bem próximo ao presídio Pemanó, a cerca de 800m. Quando chegaram os réus já estavam no bar, onde havia mais reeducandos além deles.

Inquirido pela autoridade policial, o réu Lucas confessou que engoliria as drogas para com elas ingressar no estabelecimento prisional, e que chegou a engolir duas porções, contudo, ficou bem. Pediu as drogas para um rapaz desconhecido, a fim de levá-las para dentro da prisão, nada pagando por elas. Havia acabado de descer do ônibus para retornar ao presídio Pemanó e estava com seu colega João, que também mora na cidade de Assis (fls. 17).

Já em juízo o réu Lucas assumiu a propriedade de toda a droga apreendida (encontrada fora e dentro do banheiro), entretanto, alegou que as adquiriu para o próprio uso, vindo a engolir as porções que tinha em mãos (duas “bolinhas”) ao se assustar com a presença policial no local. É da cidade de Assis e fora beneficiado com a saída temporária. Conhece o réu João, com quem veio com a excursão de ônibus até Tremembé, onde está localizado o presídio Pemanó (regime semiaberto). Como havia fila para utilizar o banheiro do ônibus e precisava fazer o uso, dirigiu-se até o bar, localizado a 700m/800m do Pemanó. No bar havia fluxo de pessoas, devido ao retorno da saída temporária, e o banheiro localizava-se aos fundos. É usuário apenas de maconha. Quando saiu do banheiro visualizou um grupo fazendo uso dessa droga. Em dois meses progrediria para o regime aberto, mas acabou “caíndo na tentação”. Como estava voltando ao presídio, comprou algumas porções de maconha, pagando R\$100,00 em 30 gramas. Na hora não contou a quantidade de porções, mas elas estavam em dois saquinhos. Teria até as 14h30min para retornar ao presídio. Pegou duas “bolinhas” e estava enrolando um cigarro de maconha quando houve a abordagem policial. No susto, mastigou as porções de maconha que tinha em mãos. Nunca havia ingerido droga antes e ficou com medo, falando a verdade aos policiais e sendo levado ao hospital – lá chegando após uma hora da ingestão dos entorpecentes – onde tomou laxante para a droga ser expelida. Frisou mais algumas vezes que a droga seria para o seu próprio uso. Possui somente uma condenação anterior, por tráfico de drogas, a respeito da qual está cumprindo pena. Veio com o réu João da cidade de Assis, no mesmo ônibus, porém, negou ter ido junto com ele até o bar, encontrando-o posteriormente naquele local. Quando saía do banheiro visualizou João chegando ao bar e entrando no banheiro logo após. Os réus e mais quinze indivíduos estavam próximos ao banheiro do bar durante a abordagem policial. Seus pertences estavam

próximos a si e no chão, enquanto as drogas que comprou estavam de frente aos pertences, pois as soltou na hora do susto. As drogas achadas no banheiro também lhe pertenciam, acreditando que lá entraram por debaixo da porta (o banheiro era simples, faltando um pedaço de madeira). Estava bem próximo ao banheiro na hora da abordagem e João não tinha nenhuma relação com as drogas. É usuário de maconha desde os 12 anos de idade, tendo passado a utilizar essa droga de forma compulsiva nos últimos tempos, pois foi diagnosticado com síndrome do pânico e ansiedade, já que permaneceu preso dos 19 aos 23 anos de idade.

O réu João, em sede policial, negou a propriedade das drogas encontradas dentro do banheiro, assim como negou ter engolido ou que iria engolir drogas para levar para dentro do presídio. Veio da cidade de Assis no mesmo ônibus que Lucas. Ao chegar, foi usar o banheiro do local dos fatos quando a polícia apareceu e o abordou. Conhece Lucas por ele ser da sua cidade, desconhecendo se ele havia engolido e/ou iria engolir mais drogas. Cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas (fls. 04).

Quando interrogado juízo o réu João novamente negou a propriedade das drogas. Alegou ser da mesma cidade que Lucas, sendo conhecidos e tendo se deslocado no mesmo ônibus. Dormiu durante a viagem e acordou com vontade de ir ao banheiro. Contudo, o banheiro do ônibus estrava "estragado", não podendo ser usado. Assim, foi ao bar - localizado a 800m do presídio - com o fim de utilizá-lo. Já no interior do banheiro escutou os policiais abordando os rapazes que estavam fora do banheiro. Espontaneamente saiu para fora do banheiro, nada sendo encontrado em sua revista pessoal. Negou ter recebido ordem policial para que saísse do banheiro. Deitou-se no chão enquanto a polícia abordava outros indivíduos. Após, foi levado para dentro do banheiro, onde estava a droga, da qual negou a propriedade ainda na abordagem policial. Anteriormente, quando adentrou no banheiro, não havia droga ou algo no chão. O réu Lucas estava próximo e já havia utilizado o banheiro. Ambos haviam ido separadamente ao local dos fatos. Havia cinco sacolas no chão, com pertences pessoais de detentos, das quais uma era dele e a outra era de Lucas. Não visualizou os policiais localizando drogas dentro dessas sacolas. Não visualizou Lucas comprando drogas, o qual já estava no bar antes de lá chegar. Negou ser usuário de drogas. Está cumprindo pena por tráfico de drogas e estava na iminência de progressão para o regime aberto (faltavam 21 dias), não havendo sentido em optar por levar drogas para o interior do presídio.

Analisadas as provas produzidas constata-se que, embora haja algumas divergências sobre alguns fatos - como a fila para uso do banheiro do ônibus descrita por Lucas, enquanto João citou que o local estava inutilizável, ou sobre a saída espontânea de João de dentro do banheiro do bar ou a existência de ordem policial para tanto - estas são irrelevantes e insuficientes para conduzir a uma decisão condenatória em relação a João, pois há fundadas dúvidas em relação à sua autoria, as quais devem prevalecer a seu favor.

O corréu João negou a prática delitiva em todas as oportunidades - durante a abordagem policial, em sede policial e em juízo - tendo os policiais civis confirmado a referida negativa de autoria. Em menos de um mês João poderia pleitear a progressão para o regime aberto (cálculo de pena a fls. 151/152), não parecendo razoável que apesar de sua experiência, pois condenado anteriormente pela mesma prática delitiva, tentaria ingressar no sistema prisional na posse de entorpecentes, dos quais ainda negou ser usuário.

Restou incontroverso que os corréus se conhecem e possuem residência na mesma cidade, contudo, tais circunstâncias não são determinantes para imputar-lhes a mesma atuação. Ambos narraram que foram separadamente ao banheiro do bar, para onde Lucas se deslocou primeiro. Após ter ele usado o banheiro, João chegou ao local. Essa dinâmica torna-se plausível frente ao que foi narrado pelos réus em juízo, inclusive explicaria a divergência acerca do funcionamento do banheiro do ônibus: seria possível que, havendo uma fila para usar o banheiro do ônibus, formada

inicialmente, Lucas teria ido ao banheiro do bar e, como João disse ter dormido durante a viagem, poderia ter despertado um pouco depois, quando já haviam verificado que o banheiro do ônibus estava inutilizável.

Por ocasião da abordagem policial João encontrava-se no banheiro do bar, e ainda que os policiais tenham determinado a sua saída, ele poderia ter se demorado um pouco mais e buscado se eximir da imputação delitiva. Apesar do contrário ser possível, o natural seria João empenhar-se em esconder ou eliminar eventual droga que trouxesse consigo – ainda mais sendo pequenas bolinhas, de fácil escoamento pelo vaso sanitário – ao invés de deixá-la aparente no centro do piso do banheiro. Além disso, do interior do banheiro João já havia escutado a ação policial, de forma que sabia da probabilidade de sua abordagem e poderia se antecipar, desvencilhando-se de substâncias que o incriminariam.

Nada foi encontrado na revista pessoal de João, o qual alegou que não tinha conhecimento da aquisição de entorpecentes por Lucas, nem do seu intuito. Os entorpecentes estavam armazenados em pequenas bolinhas (fotografia a fls. 38), cujo volume de trinta unidades não tornaria impossível, ao senso comum, a narrativa de Lucas de que eles podem ter passado por baixo da porta do banheiro quando derrubou uma das sacolas que os continha ao assustar-se com a presença policial, ainda mais porque Lucas estava bem próximo ao banheiro durante a abordagem. Não se olvide a dinâmica e animosidade da situação, podendo parte das drogas ter se deslocado para o interior do banheiro por força de algum gesto brusco com o pé, intencional ou não, pois conforme citado pelo policial Leandro, no bar havia mais reeducandos além dos réus, sendo o local público.

Perante este juízo Lucas assumiu integralmente a propriedade da droga apreendida. Mesmo que o tenha feito no intuito de beneficiar João, uma vez que Lucas já havia confessado anteriormente a propriedade de parte das drogas, inexistem motivos para duvidar dessa parte de sua confissão, ainda que tenha se retratado quanto à destinação das drogas ao tráfico. Assim sendo, de rigor a absolvição do corréu João, por insuficientes as provas de autoria.

Por outro lado, Lucas de plano confessou a propriedade das drogas encontradas do lado de fora do banheiro, próximo a si e aos seus pertences, as quais disse que pretendia ingerir com o fim de levá-las para dentro do presídio, tendo inclusive chegado a engolir duas porções. Isso confessou não somente de forma informal aos policiais que realizaram a sua abordagem, mas também quando interrogado pela autoridade policial. A confissão de Lucas ainda foi relatada pelos policiais civis nas duas oportunidades em que inquiridos, os quais desconheciam o corréu anteriormente, não tendo razões para prejudicá-lo propositalmente.

Em juízo Lucas persistiu na confissão da propriedade dos entorpecentes, e então o fez em relação à sua totalidade, assumindo também as drogas localizadas no interior do banheiro do bar. Contradizendo-se em relação às suas narrativas anteriores, assinalou que as drogas seriam destinadas ao seu próprio consumo. Contudo, em que pese tenha modificado a sua versão na fase judicial, esta restou isolada e divergente dos demais relatos, inclusive do próprio corréu quando interpelado anteriormente.

A elevada quantidade de porções apreendidas (sessenta, ou mesmo as trinta cuja propriedade foi de pronto assumida por Lucas) e a forma em que embaladas (individualizadas) são indicativos de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito a terceiros, e não ao consumo pessoal. Some-se a isso a alegada aquisição de drogas por Lucas no iminente retorno ao sistema prisional, inexistindo tempo hábil para o consumo dos entorpecentes antes do retorno ao cárcere, sendo incoerente, portanto, sua alegação de aquisição de drogas para o próprio uso.

Desacolhida a alegação de Lucas em juízo, na provável tentativa de que fosse

imputada a si uma classificação penal mais benéfica, restou claro que ele realizou a ingestão de algumas porções das drogas para com elas adentrar no sistema prisional, conforme narrou inicialmente, durante a abordagem, e em sede policial. Na ocasião, talvez receoso com sua saúde ou verificando o insucesso de seu plano inicial, comunicou o ato aos policiais civis que o abordaram e foi encaminhado para atendimento hospitalar, conforme mencionado pelo PC Leandro e comprovado pelo documento médico juntado a fls. 39.

Para o sucesso da empreitada, as drogas estavam embaladas em pequenas bolinhas, a fim de facilitar sua ingestão e posterior evacuação pelo corrêu (fotografia a fls. 38). Ressalta-se, por fim, que Lucas já é pessoa experiente na prática do tráfico de drogas, pois cumpre pena pelo mesmo delito, e ainda na eventual possibilidade de que em alguns meses pudesse requerer a progressão de regime de cumprimento de pena, optou por voltar a se imiscuir com o tráfico de drogas.

A materialidade igualmente restou comprovada, porquanto a respeito da conduta delitiva foram lavrados Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01) e Boletim de Ocorrência (fls. 28/30), registrando-se a apreensão de 60 (sessenta) porções de maconha (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 31 e Fotografia a fls. 38).

Tanto preliminarmente (Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente a fls. 33/35), como definitivamente (Laudo de Exame Químico-Toxicológico a fls. 125/127), identificou-se que a droga apreendida em poder do corrêu Lucas, com massa líquida total de 38,44g, tratava-se, efetivamente, de maconha, pois "foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), que se encontra descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)".

Frente ao exposto, incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, devendo o corrêu Lucas ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas.

Não se pode olvidar que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento prisional Pemanó, local de grande circulação/aglomeração de pessoas. Os fatos ocorreram em um bar localizado a cerca de 700m ou 800m do referido presídio, o que se confirmou pelos depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, corroborados pela prova oral produzida em juízo, por meio das declarações do policial civil Leandro e, inclusive, dos próprios réus. Tratava-se, ainda, de local público, onde também se encontravam vários outros reeducandos que em breve retornariam da saída temporária, o que reforça a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que 'o objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena prevista no inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. Com vistas a atender o escopo da norma, o rol previsto no referido inciso não deve ser encarado como se taxativo fosse, a fim de afastar a aplicação da causa de aumento de pena (REsp 1.255.249/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012)' (AgRg no AREsp 868.826/MG, j. 13/12/2018).

Além disso, o simples fato de o crime ter sido cometido nas proximidades de estabelecimento prisional já caracteriza a causa de aumento de pena supramencionada, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 138.944, tendo como Relator o Exmo. Ministro Dias Toffoli:

"Habeas Corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Precedentes. 3. Ordem denegada" (HC 138944, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 21/03/2017, Data de Publicação: DJe-170 03-08-2017). Grifou-se.

Sendo caso de condenação do corréu Lucas, procedo à dosimetria das penas com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

O réu Lucas estava em poder de quantidade de maconha que não se pode reputar exorbitante do ordinário, e não registra antecedentes desabonadores que devam ser considerados nesta fase de fixação de penas. Nesse contexto, não lhe sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, nem aquelas enumeradas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo as penas-base nos mínimos legais, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Observa-se que o réu Lucas foi condenado por tráfico de drogas nos autos nº 0000071-66.2018.8.26.0585, da 3ª Vara do Foro de Presidente Venceslau, com trânsito em julgado para as partes em abril de 2019, sobrevivendo a progressão para o regime semiaberto em 05/01/2021 (Certidão Estadual de Distribuições Criminais a fls. 91/92 e Folha de Antecedentes a fls. 93/94). Incide a agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, inc. I, e art. 63), específica na hipótese.

De outra parte, é de se reconhecer a atenuante da confissão (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd'), pois o réu sempre confirmou a propriedade das drogas e ainda que tenha negado a traficância ao ser interrogado em juízo, a confessou aos policiais civis que procederam à sua abordagem e quando interrogado pela autoridade policial, o que constituiu elemento de convicção (STJ, Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). Deve ser aplicado à hipótese o entendimento do STJ, firmado em julgamento de tese sob o rito dos recursos repetitivos, recentemente revisado, de que "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não" (Tema 585).

Reconhecidas, portanto, ambas as circunstâncias, mas compensadas entre si, as penas não sofrerão alteração nesta oportunidade de dosificação.

Conforme já citado, faz-se presente a causa de aumento de pena preconizada no art. 40, inc. III da Lei nº 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento prisional, fato confirmado pelo próprio réu. Sendo assim, elevo as penas em um sexto, a 5 anos e 10 meses de reclusão e 585 dias-multa.

A reincidência do réu Lucas impede, objetivamente, a aplicação da causa especial de diminuição de penas prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à hipótese, as

quais são tornadas definitivas nos patamares em que arbitradas.

Sendo o réu reincidente e aplicada pena privativa de liberdade de prazo superior a quatro anos, incabível sua substituição por pena restritiva de direitos, além da medida não se mostrar suficiente para a adequada repressão e prevenção de condutas similares, nem socialmente recomendável (Código Penal, art. 44, incisos I, II e III, e § 3º).

A mesma motivação importa em estabelecer o regime inicial fechado de cumprimento de pena (a contrário senso do disposto no Código Penal, art. 33, § 2º, 'b') e isso a despeito de eventual detração da pena (Código de Processo Penal, art. 387, § 2º). Ademais, o réu voltou a delinquir quando cumpria pena que lhe fora antes imposta, o que demonstra ausência de responsabilidade.

Ausentes informes específicos sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60, e Lei nº 11.343/06, art. 43), o valor unitário do dia-multa deverá corresponder ao mínimo legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião de acordo com os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Posto isso, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e:

i) absolvo João Inácio Neto dos Reis da acusação de incursão no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal; em contrapartida,
ii) condeno Lucas Moreira dos Santos à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 583 dias-multa, calculados estes no mínimo legal, por incursão no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Condeno o réu Lucas ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º), não sendo caso de suspensão da respectiva exigibilidade uma vez que nesta fase de conhecimento não houve pedido de gratuidade da justiça.

O réu Lucas foi preso em flagrante e permaneceu recolhido ao cárcere no decorrer do processo, remanescendo inalteradas as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Está sendo condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade de considerável extensão, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, havendo fundado temor de que busque eximir-se de sua responsabilização caso seja colocado em liberdade neste momento processual. Além disso, é reincidente e cumpria pena que lhe foi anteriormente imposta, em regime semiaberto, quando voltou a delinquir.

Não se mostrando adequada, nem suficiente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, determino a manutenção da medida constritiva de liberdade que anteriormente lhe foi imposta.

Recomende-se o réu Lucas no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, oficiando-se.

Por outro lado, ante a absolvição do réu João, expeça-se em seu favor, imediatamente, alvará de soltura clausulado.

Publique-se.

Intimem-se.

Taubaté, 21 de julho de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballestero
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA